

1500112-25.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Brotas

Foro: Foro de Brotas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... para negar reconhecimento ao benefício do tráfico privilegiado, devendo esse ser aplicado.6. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1949204/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DERECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brotas

Foro de Brotas

1ª Vara

Praça Nove de Julho, nº 26, Brotas-SP - cep 17380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500112-25.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500112-25.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056841/2022 - DEL.POL.ITIRAPINA, 23299310 - DEL.POL.ITIRAPINA, 126/22/605 -

DEL.POL.ITIRAPINA, 2056841 - DEL.POL.BROTAS, 126/22/605 - DEL.POL.BROTAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOAO VITOR ALMEIDA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

VISTOS.

O representante do Ministério Público denunciou JOÃO VITOR ALMEIDA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 19h50min, na Rua Carlos Rogério Algodoal, s/nº, cruzamento com a Rua José Vitor Marquezin, bairro Jardim Felicidade, nesta cidade e Comarca de Brotas, JOÃO supostamente trazia consigo, com a finalidade de venda e entrega a consumo de terceiros, 10 porções de cocaína, totalizando 6,0 gramas (peso bruto), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme narrou a denúncia, "Ao que se apurou, na data dos fatos, João Vitor trazia consigo as citadas porções de droga, acondicionadas em 10 microtubos. Assim foi que, na ocasião, policiais militares em patrulhamento de rotina ingressaram no

cruzamento das Ruas Carlos Rogério Algodoal e José Vitor Marquezin, instante em que observaram o denunciado na companhia de Carlos Eduardo de Oliveira Coelho, ambos em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o denunciado empreendeu fuga objetivando esquivar-se da abordagem policial e desfazer-se das porções de droga. Em razão da atitude tomada por João e considerando que o local é conhecido ponto de tráfico, os policiais o seguiram e procederam à abordagem pessoal. Em revista, com Carlos nada de ilícito foi localizado, havendo em seu poder apenas a quantia de R\$ 74,00 (setenta e quatro reais). Já na posse de João foram encontradas porções de drogas, sendo apreendidos 10 microtubos de cocaína e a quantia de R\$ 433,40 (quatrocentos e trinta e três reais e quarenta centavos). As porções de drogas apreendidas e já fracionadas, aliadas ao comportamento do denunciado que, ao cogitar a abordagem policial tentou se evadir e se desfazer das porções de droga que trazia consigo, assim como todas as circunstâncias de sua apreensão constituem evidências do comércio ilícito de entorpecentes."

Houve recebimento da denúncia em 19 de maio de 2022 (fls. 124/125).

O processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação da defesa prévia (fls. 98/101).

Os requerimentos da Defesa na fase do artigo 402 do CPP foram indeferidos, conforme gravado em audiência.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Pede o afastamento do privilégio do §4º do artigo 33 da LD e fixação do regime inicial fechado.

A defesa do réu JOÃO, nas alegações finais, pediu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito do artigo 28 da LD. Ainda, em caso de condenação, pede aplicação da figura privilegiada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece parcial acolhimento. O feito transcorreu regularmente. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A materialidade e autoria delitiva ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 21/23), termo de declaração (fls. 05/07, 10), laudo pericial (fls. 144/146), relatório final (fls. 82, 84/85), auto de prisão em flagrante (fls. 04), autos de exibição e apreensão (fls. 24/25) e sobretudo, pela prova oral colhida.

A testemunha de acusação LEONARDO CARDOZO PIRES, em juízo, disse que estavam em patrulhamento já visando o tráfico que é frequente naquele bairro; que quando ele viu a viatura saiu correndo; que desembarcou e o acompanhou; que ele foi dispensando tudo que tinha no bolso; que em busca pessoal, localizou 10 microtubos de cocaína no bolso e uma quantia em dinheiro no chão; que populares começaram a jogar pedra; que Carlos foi abordado por seu parceiro e João Vitor saiu correndo; que não conseguiu pegar o que ficou no chão, por conta da reação da população; que com Carlos não encontrou nada; que estava há pouco tempo no Município; que não se recorda de João Vitor ante; que não encontraram petrechos; que vê Carlos frequentemente no local; que não diligenciaram na residência; que esse bairro dos fatos é distante do Campos Elíseos.

A testemunha de acusação VICTOR LEONARDO BONFIM SGARBI, em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Felicidade, no qual há biqueiras; que Vitor saiu correndo ao ver a viatura; que o parceiro saiu correndo atrás dele; que conseguiu abordar Carlos Eduardo; que Carlos não tinha nada, apenas dinheiro; que Vitor saiu

correndo e seu parceiro o abordou; que ele o abordou na outra rua; que veio apoio de outra viatura; que já conhecia Vitor da prática de tráfico de entorpecentes; que já abordou Vitor no mesmo local; que o dono da biqueira é o Bozo, salvo engano; que Vitor está sempre ali; que ele mora duas ruas para trás dali; que não se recorda mais o que voltou da pesquisa do nome de Vitor; que ele saiu correndo quando viu a viatura; que não o visualizou vendendo ou entregando algo para alguém.

O réu JOÃO VITOR ALMEIDA, em juízo disse que trabalhava de ajudante de pintor; que ele pode falar que estava realmente trabalhando com ele; que não tinha acabado de cumprir o regime aberto; que no domingo durante a tarde estava tendo churrasco na sua casa, no Campos Eliseos; que teve discussão com sua esposa e pediu para o levarem para o bairro do Jardim Felicidade; que ficou na casa do seu amigo, ficou lá até umas 18h30, 19h; que falou que estava cumprindo RA; que viu uns moleques lá; que pegou os 10 pinos para consumo próprio; que quando subiu na rua de cima, avistou o Carlos; que ele pegou uma cerveja Antartica Subzero; que foram para a rua de cima para usar o pó; que chegando na esquina, viu duas viaturas; que sua primeira reação foi tentar correr, mas não conseguiu correr; que estava alcoolizado; que pagou 100 reais pelos 10 pinos; que o dinheiro era seu; que saiu de casa com uns 550 reais; que esse dinheiro ia ficar para o dia a dia. Como se vê, a prova é robusta para embasar a condenação, pois incontestemente que o réu praticou o núcleo "trazer consigo" drogas, previsto no art. 33, caput, da LD, tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas para a sua configuração.

Com efeito, não é crível que o acusado estivesse carregando consigo mais de 400 reais, em bairro distante de sua residência, em ponto de tráfico de drogas, na posse de entorpecentes fracionados em 10 porções para uso pessoal. A finalidade de mercancia é evidente no caso, tendo em vista o local em que se desenvolveu a ação - ponto de venda de drogas conhecido da comarca -, a considerável quantidade de porções e o testemunho hígido dos policiais, que indicaram que João inclusive teria dispensado outras porções durante a fuga, tudo a revelar, para além de uma dúvida razoável, a finalidade de mercancia (art. 28, § 2º, da LD).

Por outro lado, incide a causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006: "Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.". O réu é tecnicamente primário, pois, da certidão acostada nos autos, não é possível vislumbrar a data de trânsito em julgado da condenação pretérita. Além disso, não está comprovado que se dedica à atividade criminosa ou que integre organização criminosa, sendo certo que possui ocupação lícita, conforme comprovado pela Defesa às fls. 49.

Ainda, respeitado posicionamento diverso, entendo que ações em andamento não podem pesar em desfavor do réu para afastamento da figura privilegiada.

Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENALIDADE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADA QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENALIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Em sessão realizada no dia 14/12/2016, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, havia firmado entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso poderiam ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena

de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o que está sendo aplicado, também, pela Sexta Turma.4. Nesse contexto, esta Quinta Turma, no julgamento do HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, ocorrido em 21/9/2021, DJe27/09/2021, visando a uniformização do posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema, decidiu que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).5. No presente caso, constata-se que os processos criminais (processos criminais, autos nº 0709191-38.2016.8.02.0001, 0708024-49.2017.8.02.000 e 0001738-13.2012.8.02.0053), utilizados pela Corte local como fundamento para evidenciar a dedicação da agravante a atividades criminosas, encontram-se em andamento, ou seja, sem trânsito em julgado, o que impede o uso dessa anotação para negar reconhecimento ao benefício do tráfico privilegiado, devendo esse ser aplicado.6. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1949204/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DERECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EMCURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADEVERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE ASTURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior.3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução." (HC664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

Não socorre em favor do réu nenhuma causa excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Caracterizada, portanto, a infração penal conforme narrada pela denúncia, a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, §4º, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA

Primeira etapa:

Na primeira fase, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, combinado com artigo 42, da Lei de Drogas, denota-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; que não possui Maus antecedentes; que poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, não sendo possível tal valoração;

que o motivo do crime é inerente ao tipo em questão; que as circunstâncias do crime não são desfavoráveis, já que considero que, para agravar a pena com base no art. 42, da Lei de Drogas, tanto a quantidade (que no caso, não é ínfima, mas também não é exagerada), quanto a natureza das drogas, devem ser sopesadas em conjunto, nesse sentido: “Básicas do tráfico elevadas apenas pela espécie da droga, apesar de pequena a quantidade e, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, necessário considerar ambos os fatores de forma cumulada” (TJSP; Apelação Criminal 0000567-24.2018.8.26.0544; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020). As consequências não foram gravosas, sendo que as drogas foram apreendidas; e a circunstância do comportamento da vítima não comporta aplicação no presente caso.

Diante a esses aspectos, necessários e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, estabeleço a pena base aplicável a este caso, em sua quantidade e qualidade, nos moldes a seguir: considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa:

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes para consideração.

Terceira etapa:

Pelas razões acima já expostas, deve-se aplicar o redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006, em seu grau máximo. A pena do réu será, pois, reduzida em dois terços, atingindo o total de um ano e oito meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.

Fixo, portanto, a pena definitiva a ser aplicada ao réu em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, CP): Considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, as condições pessoais do condenado e, tendo em vista que, embora tecnicamente primário, o acusado estava em cumprimento provisório de regime inicial aberto, considero adequado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, o que faço com fundamento na Súmula n. 719 do STF.

Detração da pena (art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP): De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime.

No caso dos autos, o réu permaneceu preso processualmente por tempo considerável, porém, tendo em vista que o regime inicial foi fixado não pela quantidade de pena, pelas circunstâncias pessoais do condenado, mais apropriado que o cálculo seja realizado a título de progressão pelo Juízo da Execução, razão pela qual não se aplica a detração.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP): O Pleno do Supremo Tribunal Federal, com fundamento, principalmente, na garantia constitucional da individualização da pena, declarou inconstitucional a vedação à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos aos condenados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (HC 97256/RS, Rel. Min. Ayres Britto). Todavia, tendo em vista que o condenado estava em cumprimento provisório de regime aberto quando da prática do fato, entendo

inaplicável a substituição, porque incompatível com as circunstâncias pessoais do condenado.

Da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP): Considero inviável o Sursis também tendo em vista que o condenado encontrava-se em cumprimento provisório de regime aberto.

Fixação do valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do CP): Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado, o valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal) deve ser fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato. A pena de multa deverá ser paga nos termos e nos prazos dispostos no artigo 50 do CP, sob pena de execução.

Do direito de recorrer em liberdade/da prisão preventiva (artigo 387, §1º, do CPP): Embora fixado regime inicial semiaberto e a despeito da quantidade de pena, no caso, o condenado deve manter-se preso provisoriamente, expedindo-se ofício ao estabelecimento prisional para adequação/encaminhamento ao regime semiaberto, tendo em vista que já demonstrou propensão ao descumprimento de decisões judiciais ao descumprir o regime aberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu JOÃO VITOR ALMEIDA, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em regime inicial semiaberto.

Expeça-se ofício, com urgência, ao estabelecimento prisional onde está recolhido, para adequação da prisão preventiva/encaminhamento do condenado ao regime semiaberto.

Quanto ao dinheiro apreendido, DECRETO a sua perda em favor da UNIÃO, devendo o valor ser recolhido em favor do FUNAD, já que não comprovada sua origem lícita. Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça ora concedida.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se o IIRGD; b) comunique-se a Justiça Eleitoral (CF, art. 15, inc. III); c) expeça-se guia para a execução definitiva da pena; e d) intime-se o réu para pagamento da multa dentro de 10 (dez) dias.

Proceda-se em relação às drogas apreendidas conforme o disposto no art. 72, LD, no que ainda couber.

Atendam-se às demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, no que for pertinente.

Publique-se, intemem-se e cumpra-se.

Brotas, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA